Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 5ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:(81) 31810381

Processo nº **0046383-04.2020.8.17.2001**

AUTOR: FERNANDO ANTONIO FULCO FERREIRA

REU: UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

SENTENÇA

Vistos e examinados etc.

FERNANDO ANTONIO FULCO FERREIRA, devidamente qualificado, por meio de advogados regularmente constituídos, ajuizou a presente **AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS** em face de **Unimed Recife – Cooperativa de Trabalho Médico**, igualmente qualificada.

Em apertada síntese, narra o autor que é portador de DIABETES MELLITUS TIPO 1, fazendo uso de insulina de absorção ultrarrápida Humalog.

Pontua que para medição diária dos níveis de glicose no sangue utiliza teste de glicemia da ponta do dedo em média 10 vezes por dia, a fim de tentar manter a glicose dentro dos níveis aceitáveis.

O autor afirma que, por indicação médica, deve fazer uso dos seguintes medicamentos: a) 4 canetas de Insulina Humalog (3mL) – 39 unidades; b) 4 canetas de Insulina Glargina (3 mL) – 41 unidades; c) Material necessário para uso do FreeStyle Libre: Sensores do FreeStyle Libre – 2 unidades; Leitor do FreeStyle Libre; Caixa de tiras de fita com 50 unidades cada – 2 unidades; d) Seringas descartáveis para aplicação do medicamento.

Dá-se que a ré teria aduzido que os medicamentos em tela e o sensor de medição acima referidos não constavam de rol de cobertura prevista contratualmente, além de não encontrar previsão legal junto à ANS.

Assim, requereu a concessão de tutela provisória de urgência para que seja a ré compelida a fornecer os medicamentos e sensores narrados acima, nos moldes do que prescrevera o médico assistente.

Por fim, requereu a confirmação da tutela pretendida, além de indenização moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Anexou documentos que entendera pertinentes.

Devidamente citada, a ré aduziu que não cometera qualquer ilegalidade, tendo em visa que não há obrigatoriedade de fornecimento de medicamento para uso domiciliar, distante do âmbito hospitalar.

Aduziu, ainda, que a utilização do sensor epigrafado não é a única forma de monitoramento, sendo um dos métodos disponíveis no mercado.

Pontuou que em nenhum momento restringiu a cobertura contratual, tampouco houve abusividade por parte da Operadora, ao contrário disso, agiu de acordo com o previsto nas Condições Gerais do contrato, não podendo, de nenhuma sorte, ser compelida a proceder em desacordo com o disposto contratualmente e em desacordo com a legislação aplicável.

Desta forma, ante a ausência de qualquer conduta ilícita, resta indevida a pretensão relativa ao dano moral.

Requereu a improcedência da ação em todos os seus termos.

Anexou aos autos documentos que entendera pertinentes.

Réplica devidamente anexada aos autos, reafirmando os termos da inicial.

É o sucinto relatório. Passa-se ao julgamento.

A presente hipótese dispensa a produção de novas provas, comportando julgamento no estado em que atualmente se encontra, nos termos do artigo 355, I, do CPC.

Trata-se de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

Resta incontroverso que a parte autora mantém contrato de plano de saúde com a ré, estando em dia com o pagamento das mensalidades correspondentes. Ainda, resta indene de dúvidas que a parte demandante foi diagnosticada com DIABETES MELLITUS TIPO 1.

No entanto, apesar da imprescindibilidade do tratamento para garantir uma melhor qualidade de vida, o plano de saúde o negou, sob a justificativa de que o aludido tratamento não teria cobertura contratual.

O plano não poderia escusar-se ao tratamento da parte autora.

Vejamos entendimento recente do STJ sobre o tema:

> AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA N. 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O entendimento firmado no âmbito desta Corte Superior é no sentido de que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. **Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário**" (AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1º/6/2020, DJe 15/6/2020) 2. De fato, "é pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo" (AgInt no REsp n. 1.841.742/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1º/6/2020, DJe 4/6/2020).

3. Não há como afastar a premissa alcançada pelo acórdão quanto à configuração da falha na prestação do serviço hospitalar e o consequente dever de reparação moral na hipótese, sem proceder ao revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.

4. Segundo a orientação deste Tribunal, o quantum estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso, de modo que a sua revisão também encontra óbice na Súmula n. 7/STJ

5. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Dessa forma, há a necessidade de ser a causa decidida à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos respectivos dispositivos legais, interpretando-se sua aplicação ou não ao caso concreto.

5. 1. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, o recorrente suscitar a

violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau.

6. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1704820/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Há de se ressaltar que quem averigua a situação concreta de enfermidade do paciente e prescreve o adequado tratamento é o profissional médico. Aquiescer com a conduta da operadora, de negar a cobertura de tratamento prescrito por médico assitente, sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida em rol previsto pela ANS, ou cláusula contratual, é medida que não se mostra razoável.

Assim, ao meu sentir, a recusa é indevida e injustificada, merecendo ser judicialmente afastada, priorizando-se, dessa maneira, o direito da parte demandante, o qual revela-se correto e justo.

Outrossim, entendo que cabe ao médico a definição do melhor tratamento a ser ministrado ao paciente, diante da doença por ele apresentada, não cabendo ao plano se imiscuir nessa decisão, sob pena de intervenção indevida no proceder do profissional, que tem a competência para elidir a enfermidade que aflige o autor.

Neste sentido, vale colacionar julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, em caso similar:

"PLANO DE SAÚDE Cerceamento de Defesa Inexistência - Autora diagnosticada com Diabetes Mellitus Tipo 1 Tratamentos anteriores que não lograram controlar a glicemia da paciente Bomba de insulina - Equipamento de uso domiciliar. Exclusão contratual. Inadmissibilidade. Não excluindo a operadora do plano de saúde a doença, não podem ser excluídos os procedimentos, medicamentos, materiais e exames necessários ao tratamento consoante a prescrição do médico assistência Irrelevância da possibilidade

da existência de outros tratamentos - Legitimidade passiva ad causam da Operadora diante da cobertura da doença - Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1025524-55.2019.8.26.0506; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4ª Câmara de DireitoPrivado; Foro de Ribeirão Preto - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/01/2021; Data de Registro: 11/01/2021)".

"SEGURO SAÚDE. Negativa de fornecimento de bomba de insulina e dos insumos necessários ao seu efetivo funcionamento, indicados para o tratamento de Diabetes Melito Tipo 1. Situação grave atestada em laudo médico, funcionando o tratamento como último recurso para a preservação da integridade física do paciente. Incidência do CDC (Súmula 608,STJ). Abusividade da cláusula restritiva capaz de colocar em risco o objeto do contrato (art. 51,IV, CDC). **Irrelevância de não estarem os procedimentos previstos no contrato ou no rol da ANS (Súmulas 96 e 102, TJSP). Fornecimento devido. Atenuação do "pacta sunt servanda" em prol de valores que permeiam a dignidade da pessoa humana**. Cobertura devida. Sentença mantida. Afastamento da alegação de pedido genérico, já que o tratamento prescrito, contínuo e ininterrupto, não está sujeito a uma data-limite de cobertura. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% do valor atualizado da causa (art. 85, §11, CPC). RECURSODESPROVIDO, majorados os honorários fixados em Primeiro Grau". (TJSP; Apelação Cível1101995-69.2019.8.26.0100; Relator (a): Beretta da Silveira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/08/2020; Data de Registro: 19/08/2020)".

Desta forma, o que se extrai dos autos, portanto, é que a recusa é ilegítima.

Pois bem. Uma vez verificada a conduta ilícita praticada pela operadora de saúde ré, de rigor, é o acolhimento do pedido de autor em ver-se afastada qualquer cláusula contratual que afaste o dever de cobertura do

tratamento narrado ao longo destes autos.

Nesse sentido, vale colacionar o seguinte julgado:

> "CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NEGATIVA A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. GASTROPLASTIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA NEGATIVA. SÚMULA Nº 10 DO TJPE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362/STJ E ART. 405 do CC/2002. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. **A seguradora não substitui o médico responsável pelo tratamento e o plano, em tese, apenas define as doenças que terão cobertura, não podendo impedir a realização de cirurgia gástrica para obesidade mórbida, especialmente quando evidenciada a imprescindibilidade do tratamento cirúrgico para a saúde da paciente, como se depreende do laudo elaborado pelo médico assistente da autora**. Súmula 10 do TJPE: "**É abusiva a negativa de cobertura da gastroplastia para tratamento da obesidade mórbida**." /2. "Embora geralmente o mero inadimplemento contratual não seja causa para ocorrência de danos morais, é reconhecido o direito à compensação dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada" (STJ - AgRg no REsp 1.328.978/RS - Terceira Turma - Rel. Min. Nancy Andrighi - Julg. 13.11.2012 - DJe 20.11.2012);3. Levando em consideração as circunstâncias do caso, o valor arbitrado pelo juiz de primeiro grau foi demasiadamente baixo, razão pela qual o valor deve ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).4. Na responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/2002: "Contam-se os juros de mora desde a citação inicial" e a correção monetária a partir do julgamento em que arbitrado

o valor da indenização (Súmula 362/STJ).5. Majoração dos honorários advocatícios para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 6. Recurso parcialmente provido.

(Apelação Cível 514941-50005572-68.2010.8.17.1090, Rel. Roberto da Silva Maia, 1ª Câmara Cível, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020)".

Feitas tais considerações, resta ponderar que a recusa referenciada aumenta a situação de angústia e aflição da autor, que, já acometido pela doença de que é portador, cujo tratamento é intenso e incessante, foi surpreendido com a negativa da operadora de plano de saúde, a qual se encontra vinculada.

Os danos morais ficam demonstrados no caso vertente, se configurando, sobretudo, *in re ipsa*, sem necessidade de demonstração do efetivo prejuízo por que passou a demandante.

Quanto ao montante, deve-se ter em conta as especificidades do caso concreto, ou seja, as particularidades que circunscrevem o caso em apreciação.

Além disso, o juiz tem a obrigação de se ater a outros parâmetros, como proporcionalidade e razoabilidade na fixação do *quantum*, à extensão do dano, às capacidades econômicas da vítima e do ofensor, etc.

Levando em consideração todos esses aspectos, tenho por bem fixar a quantia em **R$ 5.000,00 (cinco mil reais)**, deixando claro que a fixação em montante inferior ao pleiteado não induz sucumbência recíproca, conforme entendimento do STJ.

Ante o exposto, e de acordo com a fundamentação supra, resolvo **JULGAR PROCEDENTES** os pedidos elencados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, o que faço com amparo no artigo 487, inciso I, do NCPC, para o fim de:

a) **DEFERIR** a tutela em sentença, a fim de que a ré, no prazo de 15 dias, proceda com o custeio do fornecimento mensal de: **I)** 4 unidades de Humalog 3 mL; **II)** 4 unidades de Glargina 3 mL;

III) 2 sensores do FreeStyle Libre, com material necessário ao seu uso –**IV)** Leitor do FreeStyle Libre; **V)** 2 caixas de tira de fitas com 50 unidades cada; além das seringas descartáveis necessárias às aplicações, sob pena de multa de R$ 500,00, limitada ao valor causa;

b) **DECLARAR** nulas as cláusulas contratuais que vedem o fornecimento dos medicamentos constantes dos laudos médicos anexados aos autos, ID'S **67286438, 67286441 e 67286442;**

c) **CONDENAR** a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ **5.000,00 (cinco mil reais**), com correção monetária pelo ENCOGE a partir da data do arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês a partir da efetiva citação.

Ante a sucumbência em tela, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do que prescreve o artigo 85, §2º, do NCPC.

P.R.I.

Recife, 07 de abril de 2021.

Janduhy Finizola da Cunha Filho

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: JANDUHY FINIZOLA DA CUNHA FILHO
07/04/2021 15:28:39
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 78233244

21040715283918800000076638044